Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Três Coroas

Rua Felipe Bender, 373 - Bairro: Centro - CEP: 95660000 - Fone: (51) 3098-5595 - Email: frtrescoroas1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000426-55.2023.8.21.0164/RS

AUTOR: BIANCA COLLET

RÉU: UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA.

SENTENÇA

I - Relatório

BIANCA COLLET ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de antecipação de tutela para fornecimento de medicamentos contra UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. Narrou que está com 21 semanas de gestação e, após diversos exames e consulta com especialistas, recebeu o diagnóstico de Síndrome Antifosfolípide (SAF) CID 10: D 68.8. Pontuou que esta patologia (trombofilia), está associada a abortamentos de repetição, restrição de crescimento intrauterino e morte fetal, assim como complicações maternas, como eventos tromboembólicos que podem evoluir a embolias pulmonares cerebrais e até a óbito. Para o tratamento, a recomendação médica foi para o uso do medicamento enoxaparina 40mg, 1 injeção subcutânea por dia, durante todo o período gestacional e pós parto. Pediu, em tutela provisória de urgência, que a ré forneça o medicamento indicado pelo médico. Ao final, requereu a confirmação da tutela provisória e a procedência dos pedidos, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento até o final da gravidez ou conforme a orientação de seu médico assistente, sob pena de ressarcimento dos gastos suportados pela autora na aquisição do medicamento; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelo abalo psicológico sofrido em situação de risco para a saúde materna e fetal. Requereu a concessão da gratuidade judiciária. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Foi concedido o benefício da justiça gratuita e deferida a tutela provisória de urgência (evento 3, DESPADEC1).

Citada, a ré contestou (evento 14, CONT1). Pontuou o caráter domiciliar do fármaco postulado. Disse que, não se tratando de antineoplástico, a oferta de medicamento domiciliar está expressamente excluída do contrato, o que mencionou estar referendado pelo art. 10, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98, não sendo ponto excepcionado pelo art. 12 da mencionada lei. Discorreu sobre a legislação aplicável. Sustentou ser inaplicável a inversão do ônus da prova. Argumentou que, não havendo descumprimento contratual, não há falar em danos morais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados. Juntou documentos.

A autora requereu, por orientação médica, o aumento da dose fornecida (evento 15, PED LIMINAR_ANT TUTE1), o que foi deferido pelo juízo (evento 21, DESPADEC1).

Houve réplica (evento 30, RÉPLICA1).

Intimadas as partes sobre o interesse na produção de outras provas (evento 32, DESPADEC1), postularam o julgamento antecipado do mérito (evento 36, PET1) (evento 37, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

II - Fundamentação

O processo tramitou regularmente, com a observância de todas as formalidades legais, estando isento de vícios ou irregularidades.

Cabível o julgamento antecipado do mérito, em razão da matéria discutida, não sendo necessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Inexistindo preliminares a serem examinadas, passo à análise do mérito.

De início, observo que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na interpretação do contrato deverá ser observado o disposto no art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

> *Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Sobre o tema, cabe evidenciar a divergência a respeito do caráter do rol de procedimentos publicado pela ANS, se exemplificativo ou taxativo.

Em 08.06.2022, a 2ª Seção do STJ decidiu que o rol é, em regra, taxativo:

1 - O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

STJ. 2ª Seção.EREsp 1.886.929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022 (Info 740).

Contudo, em notória reação legislativa (chamado efeito *backlash*), adveio a Lei n.º 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), incluindo o §12, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS:

Art. 10. (...)

§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

A Lei n.º 14.454/2022 entrou em vigor no dia 22.09.2022.

Ademais, não se pode descurar do disposto no art. 4º, inciso III, da Lei 9.661/00, normativa que criou Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS:

Art. 4º Compete à ANS:

*III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, **que constituirão <u>referência básica</u>** para os fins do disposto na Lei n.º 9.656/98, e suas excepcionalidades;*

Assim, diante da legitimidade democrática que se reveste a produção legislativa e considerando que decisão do STJ é desprovida de caráter vinculante, posiciono-me no sentido de que o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde.

Desta forma, o fato de o procedimento médico que se pretende obter cobertura não constar no rol da ANS, por si só, não excetua sua cobertura.

Nesse sentido, aponto precedentes do Tribunal de Justiça do Estado:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO BELIMUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. **AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI.** NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. **<u>NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14.454/2022</u>**. (...). 7. DE CONSEQUÊNCIA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC, RESTAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50034053920218210041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-06-2023)*

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TROMBOFILIA GESTACIONAL. MEDICAMENTO DENOMINADO ENOXAPARINA (CLEXANE). COBERTURA DEVIDA. 1. OS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 9.656/98 AO CASO EM TELA, DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL E MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. (...). 4. **<u>ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO, PREVENDO APENAS A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA A SER ASSEGURADA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE</u>**. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50066174320218210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 14-12-2022)*

Inclusive, com lastro no entendimento de que o plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado, assim como que o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado, foi concedida a tutela provisória de urgência, em 23.02.2023, com respaldo de precedente da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, cujo julgamento ocorreu em 14.12.2022.

A saber:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TROMBOFILIA GESTACIONAL. MEDICAMENTO DENOMINADO ENOXAPARINA (CLEXANE). COBERTURA DEVIDA. 1. OS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 9.656/98 AO CASO EM TELA, DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL E MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. 2. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA O SEGURADO. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA NO CONTRATO PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, NÃO IMPORTANDO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ MINISTRADO. 3. HIPÓTESE EM QUE AS PECULIARIDADES DO CASO DEMONSTRAM QUE O TRATAMENTO RECOMENDADO SE REVELA NECESSÁRIO PARA EVITAR FENÔMENOS TROMBOEMBÓLICOS DECORRENTES DA SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE, BEM COMO DOS RISCOS QUE A MOLÉSTIA CAUSA A GESTANTE E NASCITURO. 4. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO, PREVENDO APENAS A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA A SER ASSEGURADA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50066174320218210017, **Quinta Câmara Cível**, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: **14-12-2022**)*

*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TROMBOFILIA HETEROZIGOZE. TRATAMENTO DOMICILIAR. MEDICAMENTO ENOXOPARINA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A AUTORA, EM ESTADO GESTACIONAL, É PORTADORA DE TROMBOFILIA HETEROZIGOZE (CID 10 D68), NECESSITANDO, COM URGÊNCIA, DO TRATAMENTO COM O FÁRMACO ENOXAPARINA - 40 MG, UMA VEZ AO DIA ATÉ SEIS SEMANAS APÓS O PARTO. A COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO FOI NEGADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE É DE USO DOMICILIAR E NÃO CONSTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. II. ENTRETANTO, OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA NESTA RELAÇÃO. DE OUTRO LADO, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, AINDA QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS, O QUAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO STJ, OU NÃO PREENCHIDA A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC. III. OUTROSSIM, **CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O LOCAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO É IRRELEVANTE PARA DEFINIR O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. EM OUTRAS PALAVRAS, SE HÁ COBERTURA PARA A DOENÇA, DEVE SER FORNECIDO O MEDICAMENTO MINISTRADO PELO MÉDICO, MESMO QUE PARA USO DOMICILIAR. ALÉM DO MAIS, DEVE SER PRIORIZADO O DIREITO À SAÚDE E À VIDA EM RELAÇÃO AO DIREITO CONTRATUAL**. IV. PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO. V. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50041190820208210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 15-12-2021)*

No mesmo sentido: Apelação Cível, Nº 50094563320198210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-08-2020.

Aliás, nessa linha foi a posição da Desembargadora Relatora LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA, da Quinta Câmara Cível do TJ/RS, que, em **01.03.2023**, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo interposto pela ré contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência (processo 5046297-67.2023.8.21.7000/TJRS, evento 7, DESPADEC1).

Não obstante, cabe assinalar que a matéria em exame passou por modificação de entendimento pela própria Câmara acima referida, tendo a Des. Rel. LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA consignado, em seu voto, no julgamento da apelação cível nº 5003405-39.2021.8.21.0041/RS, desprovida por unanimidade, o seguinte trecho:

*"Dito isso e considerando a recente jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita, que considera legítima a recusa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos ou de uso em regime de home care, **destaco que revi o meu posicionamento anteriormente exarado acerca da matéria**."*

Ementa do acórdão mencionado:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO BELIMUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14.454/2022. 4. **NÃO OBSTANTE O CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS, SALIENTA-SE QUE O ART. 10 DA LEI 9.656/98 APRESENTA HIPÓTESES EXPRESSAS EM QUE SE POSSIBILITA A EXCLUSÃO DE COBERTURA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE, DENTRE AS QUAIS ESTÁ INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, À EXCEÇÃO DOS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E MEDICAÇÕES EM REGIME DE HOME CARE. 5. NESSE CONTEXTO E CONSIDERANDO A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA, AS OPERADORAS DE SAÚDE, SALVO CONTRATAÇÃO QUE AMPLIE O ÂMBITO DE COBERTURA, NÃO DETÊM OBRIGAÇÃO DE COBRIR MEDICAMENTOS QUANDO EM USO DOMICILIAR, EXCETUADOS OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E MEDICAÇÕES EM REGIME DE HOME CARE - HIPÓTESES DISTINTAS DA QUE SE OBSERVA NO PRESENTE FEITO**. 6. DITO ISSO, NÃO HÁ FALAR EM DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DO MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PLEITEADO, AFIGURANDO-SE LEGÍTIMA A RECUSA DE FORNECIMENTO. 7. DE CONSEQUÊNCIA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC, RESTAM MAJORADOS OS*

*HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50034053920218210041, **Quinta Câmara Cível**, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: **28-06-2023**)*

Com a alteração de posicionamento, passou a ser entendido que, não obstante o caráter exemplificativo do rol da ANS, **o art. 10 da Lei 9.656/98 apresenta hipóteses expressas em que se possibilita a exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, dentre as quais está incluído o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar**, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care*.

É a previsão legal:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Com base nisso, formou-se entendimento de que **é considerada legítima a recusa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos ou de uso em regime de *home care***.

Portanto, pela compreensão atual, as operadoras de saúde, salvo contratação que amplie o âmbito de cobertura, não detêm obrigação de cobrir medicamentos quando em uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care* - hipóteses distintas da que se observa no presente feito.

A respeito do tema, há precedente decidindo pela admissão de recurso especial que enfrenta a matéria:

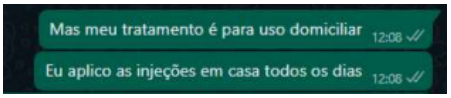
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TROMBOFILIA GESTACIONAL. ENOXAPARINA (CLEXANE). AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA COBERTURA DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. RAZÕES RECURSAIS QUE ENCONTRAM GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. RECURSO ADMITIDO. (Apelação Cível, Nº 50066174320218210017, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 05-06-2023)

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TROMBOFILIA GESTACIONAL. MEDICAMENTO DENOMINADO ENOXAPARINA. COBERTURA INDEVIDA. RETORNO DO STJ. NOVO JULGAMENTO. 1. OS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 9.656/98 AO CASO EM TELA, DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL E MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. 2. **NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ, NÃO SE AFIGURA ILÍCITA A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (E CORRELACIONADOS), A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM**. 3. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000826920198210114, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-03-2023)*

Destarte, não obstante tenha decido pela concessão da tutela provisória de urgência, o que fiz em análise de cognição sumária e com suporte de precedente da época, o exame do mérito requerer um estudo aprofundado e em atenção ao conjunto normativo incidente, assim como ao posicionamento jurisprudencial, o qual passo a observar para o exame em cognição exauriente.

Veja-se, parte autora postulou a cobertura pela ré do medicamento enoxaparina de 60mg (evento 1, INIC1) (evento 1, LAUDO5) (evento 15, PED LIMINAR_ANT TUTE1), o qual consiste em fármaco de uso domiciliar - que não se enquadra nas exceções legalmente previstas (antineoplásico ou de uso em regime de *home care*).

Aliás, a respeito da administração do medicamento pela própria paciente, tem-se a conversa anexada pela autora que menciona ser ela mesma quem aplica as injeções (p. 7, evento 1, OUT6):



Outrossim, o contrato expressamente dispõe sobre a exclusão de fornecimento de medicamento fora do regime de internação hospitalar e qualquer serviço ambulatorial exclusivo para aplicação de medicamento que pode ser realizado no domicílio (p. 32 e 33, evento 1, CONTR8):

TEMA IV . EXCLUSÕES DE COBERTURA

Cláusula 51: Estão expressamente excluídos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuízo das limitações previstas nas cláusulas subseqüentes, os seguintes procedimentos:
I. casos de cataclismos, guerras e comoções internas no país, quando declarados pela autoridade competente;
II. internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar;
III. consultas e atendimentos domiciliares;
IV. fornecimento de medicamentos, materiais, próteses e órteses estrangeiras, que não estejam nacionalizados ou que possuam similiar nacional, e sem registro vigente na ANVISA;
V. fornecimento de próteses, órteses, stents, marca-passos, geradores, válvulas, acessórios e outros, não ligados ao ato cirúrgico, em qualquer hipótese;
VI. fornecimento de todo e qualquer tipo de medicamento, material, equipamento e enfermagem para tratamento fora do regime de internação hospitalar;

XI. qualquer serviço ambulatorial exclusivo para aplicação de medicamento que pode ser realizado no domicílio do beneficiário, sem cobertura contratual;

Com efeito, ante a ausência de previsão contratual para a cobertura de medicações de uso domiciliar (pelo contrário, tem-se a expressa exclusão do fornecimento pretendido), que encontra respaldo legal de exclusão de cobertura (art. 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98), não há falar em dever de fornecimento pela operadora do plano de saúde, afigurando-se legítima a recusa pela ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO BELIMUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. (...) 5. ***NESSE CONTEXTO E CONSIDERANDO A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA, AS OPERADORAS DE SAÚDE, SALVO CONTRATAÇÃO QUE AMPLIE O ÂMBITO DE COBERTURA, NÃO DETÊM OBRIGAÇÃO DE COBRIR MEDICAMENTOS QUANDO EM USO DOMICILIAR, EXCETUADOS OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E MEDICAÇÕES EM REGIME DE HOME CARE - HIPÓTESES DISTINTAS DA QUE SE OBSERVA NO PRESENTE FEITO. 6. DITO ISSO, NÃO HÁ FALAR EM DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DO MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PLEITEADO, AFIGURANDO-SE LEGÍTIMA A RECUSA DE FORNECIMENTO****. 7. DE CONSEQUÊNCIA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC, RESTAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50034053920218210041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-06-2023)*

Para finalizar, vale consignar que, para que a situação se excepcione e possibilite a mitigação do referido entendimento, há que se demonstrar que a administração da medicação depende de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, visto que nesta hipótese não seria mais considerado como tratamento domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
4. ***A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar****.*
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.989.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

Todavia, a aludida excepcionalidade não foi demonstrada no autos, de forma que se impõe a observância da exclusão de cobertura de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98.

De outra parte, não tendo sido verificado o descumprimento contratual pela ré, não há falar em danos morais decorrente da recusa de fornecimento do medicamento pretendido. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não a parte produzido qualquer prova que evidenciasse o referido dano, motivo pelo qual improcede o pedido.

Destarte, diante da análise realizada em cognição exauriente e em atenção ao recente posicionamento jurisprudencial sobre o tema, **REVOGO a tutela provisória de urgência concedida**, impondo-se a improcedência dos pedidos.

III - Dispositivo

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, REVOGO a tutela provisória de urgência e julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BIANCA COLLET contra UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da fixação (prolação da sentença), e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 85, §16, do CPC). Contudo, a exigibilidade dos encargos fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Caso seja interposto recurso de apelação, deve-se observar a disposição contida no art. 1.010 do CPC, com intimação da parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias (§1º), o mesmo sendo observado para hipótese de recurso adesivo (§2º).

Após, as referidas formalidades, os autos deverão ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do §3º do dispositivo em epígrafe.

Nada sendo requerido, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.

Três Coroas, 10 de Julho de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **VIVIAN FELICIANO, Juíza de Direito**, em 31/7/2023, às 19:1:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10041823891v54** e o código CRC **00923f98**.